

MAIZATUL AZNIN BINTI MOHAMED

lwn.

SALIHIN BIN ISMAIL

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Haji Othman Bin Ibrahim (Ahli Panel)

Kes Rayuan No. : 10000-075-0150-2018

[Rayuan Terhadap Perintah Pengkomitan - Seksyen 151 (1) (b) (aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Encik Fakhru Azman Bin Abu Hasan daripada Tetuan Azaine & Fakhru

Peguam Syarie Responden: Tidak Diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Rayuan ini adalah terhadap keseluruhan keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 5 Disember 2018 dalam kes permohonan no. 10400-075-0734-2017, sebagaimana berikut;

- 1.1 *Mahkamah meluluskan Permohonan Pengkomitan Pemohon berdasarkan Subperenggan 151(1) (a) (aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;*
- 1.2 *Mahkamah memerintahkan bahawa Responden disabitkan telah melanggar Perenggan 6 Penghakiman bertarikh 17 April 2017; dan*
- 1.3 *Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah dikomitkan ke penjara selama tiga (3) hari mulai hari ini.*

2) Perayu tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 5 Disember 2018 dan mengemukakan lapan (8) alasan rayuan bertarikh 10 April 2019 seperti di muka surat 294-298 Rekod Rayuan.

FAKTA KES

3) Perayu dan Responden telah bercerai pada 1 Februari 2016 dan mempunyai tiga orang anak iaitu;

BIL	NAMA	NO MyKAD/MyKID	UMUR
1	Mifzal Bin Salihin	011010-14-0453	18 tahun

2	Muqrish Bin Salihin	041204-14-0509	15 tahun
3	Mohsin Bin Salihin	120406-10-1933	7 tahun

4) Selepas perceraian, Perayu telah memfailkan suatu tindakan hak jagaan anak ke atas anak-anak tersebut melalui Saman No. 10400-028-0038-2015. Kemudian pada 17 April 2017, Mahkamah telah memutuskan bahawa;

“ 1. Mahkamah meluluskan tuntutan ini berdasarkan kepada Seksyen 82 dan Seksyen 85(2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003;

2. Mahkamah memerintahkan hak jagaan ke atas anak yang bernama Mifzal (No. MyKad: 011010-14-0453) dan Muqrish Bin Salihin (No. MyKid: 041204-14-0509) hendaklah diserahkan kepada Defendan (bapa) berdasarkan Seksyen 85(2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor);

3. Mahkamah memerintahkan hak jagaan ke atas anak yang bernama Mohsin Bin Salihin (No MyKid: 120406-10-1933) hendaklah diserahkan kepada Plaintiff (ibu) berdasarkan kepada Seksyen 82 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor);

4. Mahkamah memerintahkan Plaintiff (ibu) hendaklah diberikan hak lawatan ke atas anak yang bernama Mifzal (No. MyKad: 011010-14-0453) dan Muqrish Bin Salihin (No. MyKid: 041204-14-0509) pada bila-bila masa yang munasabah bergantung kepada kehendak anak-anak tersebut;

5. Mahkamah memerintahkan Defendan (bapa) hendaklah diberikan hak lawatan ke atas anak yang bernama Mohsin Bin Salihin (No MyKid: 120406-10-1933) pada hujung minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan bermula jam 12.00 tengah hari Jumaat dan hendaklah dikembalikan semulakepada Plaintiff pada hari Ahad jam 6.00 petang dengan urusan pengambilan hendaklah dimaklumkan kepada Plaintiff terlebih dahulu;

6. Mahkamah memerintahkan Defendan (bapa) hendaklah diberikan hak lawatan ke atas anak yang bernama Mohsin Bin Salihin (No MyKid: 120406-10-1933) pada hari Isnin dan Rabu minggu pertama dan minggu ketiga serta hari Selasa dan Khamis minggu kedua dan keempat setiap bulan antara jam 6.00 petang sehingga jam 9.00 malam dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Plaintiff.

7. *Mahkamah memerintahkan hak cuti persekolahan hendaklah diberikan kepada Plaintiff dan Defendan secara sama rata dengan dimulai dengan Plaintiff dan disambung dengan Defendan bergantung kepada kehendak anak-anak tersebut; dan*

8. *Mahkamah memerintahkan hak berhari raya hendaklah diberikan secara bergilir-gilir dengan hari raya Aidilfitri pada tahun 1438H (2016) anak-anak tersebut akan bersama Plaintiff manakala hari raya Aidiladha anak-anak tersebut akan bersama Defendan dan hari raya Aidilfitri pada tahun 1439H (2017) anak-anak tersebut akan bersama Defendan dan hari raya Aidiladha anak-anak tersebut akan bersama Plaintiff dan kaedah ini berterusan pada tahun berikutnya. “*

5) Responden telah memfailkan suatu Permohonan untuk mendapatkan kebenaran menguatkuasakan perintah melalui suatu tindakan pengkomitan pada 12 Oktober 2017 berdasarkan Subperenggan 151 (1) (b) (aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 kerana Perayu telah melanggar Perenggan 5, 6, 7 dan 8 Perintah Mahkamah berdasarkan kepada beberapa kejadian yang telah dinyatakan oleh Responden dalam Afidavit Sokongannya.

6) Pada 6 November 2017, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan perintah kebenaran bahawa:

1. *Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan Subperenggan 151 (1) (aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*
2. *Mahkamah memerintahkan suatu Notis Tunjuk Sebab hendaklah dikeluarkan dan diserahkan kepada Responden untuk membela diri daripada dikenakan tindakan pengkomitan kerana sengaja engkar atau cuai atau melanggar Perenggan 5 (kejadian pada 11.08.2017) dan Perenggan 6 (kejadian pada 10.08.2017) Perintah Mahkamah bertarikh 17 April 2017 dalam Saman No. 10400-028-0038-2015.*
3. *Mahkamah memerintahkan Notis Tunjuk Sebab dan sesalanan Perintah ini hendaklah diserahkan oleh Pemohon secara kediri kepada Responden.*
4. *Mahkamah memerintahkan kes ini hendaklah disebut semula pada 12/12/2017 jam 9.00 pagi.*

6) Perayu kemudiannya telah memfailkan suatu Afidavit Jawapan pada 1 Oktober 2018 sebagai pembelaan dan Responden memfailkan Afidavit Balasan pada 15 Oktober 2018.

7) Seterusnya pada 5 Disember 2018, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan suatu perintah yang telah mengkomitkan Perayu ke penjara selama 3 hari.

8) Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut Perayu telah memfailkan Notis Rayuan serta Permohonan Penggantungan Pelaksanaan Perintah melalui Permohonan No. 10400-064-0803-2018.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

9) Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Oleh kerana rayuan ini hanya melibatkan keputusan berkaitan pelanggaran terhadap Perenggan 6 Penghakiman bertarikh 17 April 2017 dan tindakan diambil berdasarkan peruntukan Subperenggan 151 (1) (b) (aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 maka isu-isu lain yang di luar daripada skop yang berkenaan dan tidak berkaitan tidak akan kami pertimbangkan. Sehubungan dengan itu kami akan rangkumkan kesemua alasan rayuan Perayu kepada satu isu sahaja

iaitu sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memerintahkan Perayu dikomitkan ke penjara selama tiga(3) hari setelah disabitkan melanggar Perenggan 6, Penghakiman bertarikh 17 April 2017.

10) Berdasarkan penelitian kami terhadap rekod rayuan, kami membuat dapatan seperti berikut;

10.1 Responden telah memfailkan Permohonan untuk mendapatkan kebenaran menguatkuasakan perintah melalui tindakan pengkomitan berdasarkan peruntukan Subperenggan 151 (1) (b) (aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 pada 12 Oktober 2017.

10.2 Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 6 November 2017 telah memberi kebenaran kepada Responden untuk memulakan prosiding pengkomitan dan mengarahkan suatu Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan kepada Perayu kerana sengaja engkar atau cuai atau melanggar Perenggan 5 (Kejadian pada 11 Ogos 2017) dan Perenggan 6 (Kejadian pada 10 Ogos 2017) Perintah Mahkamah bertarikh 17 April 2017 dalam Saman No. 10400-028-0038-2015).

10.3 Notis Tunjuk Sebab tersebut beserta Notis Permohonan dan Affidavit serta Perintah Kebenaran Mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab telah diserahkan oleh Responden kepada Perayu pada 26 Julai 2018 iaitu 18 hari sebelum kes disebut semula pada 13 Ogos 2018. Perayu kemudiannya telah memfailkan Affidavit Jawapan pada 1 Oktober 2018 sebagai pembelaan dan Responden memfailkan Affidavit Balasan pada 15 Oktober 2018.

10.4 Pada 5 Disember 2018, Pendaftar telah membacakan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang mensabitkan bahawa Perayu telah melanggar Perenggan 6 Penghakiman bertarikh 17 April 2017 dan memerintahkan Perayu dikomitkan ke penjara selama tiga (3) hari.

10.5 YA Hakim Bicara di muka surat 287 Rekod Rayuan telah mensabitkan Perayu melanggar Perenggan 6 Perintah berdasarkan ulasannya;

“ Mahkamah berpendapat bahawa Pemohon sememangnya telah diberikan hak lawatan ke atas anak tersebut pada 10.08.2017 kerana ia jatuh pada hari Khamis minggu kedua pada bulan tersebut. Mahkamah melihat bahawa Responden telah melanggar Perenggan 6

berdasarkan kejadian yang berlaku pada 10.08.2017 kerana;

- i. Pemohon telah memaklumkan kepada Responden pada jam 11.28 pagi akan kehendaknya untuk melawat anak tersebut dan ia telah disedari oleh Responden menerusi jawapan balasnya pada 5.18 petang.*
- ii. Pemohon telah tiba di hadapan rumah Responden pada jam 5.30 petang dan telah menunggu selama 53 minit iaitu sehingga jam 6.23 petang.*
- iii. Anak tersebut tiada kelas lain selepas jam 6.00 petang tersebut.*
- iv. Alasan Responden bahawa pada hari Khamis, 10.08.2017 tersebut, anak tersebut tamat sesi persekolahan pada jam 6.00 petang dan keadaan hujan serta keadaan trafik yang tidak mengizinkan tidak boleh diterima kerana aktiviti di "Stay N Play" terletak di Level 1, Block 1, Amaya Saujana Condo, Persiaran Golf, Seksyen U2, 40150 Shah Alam, Selangor iaitu dikawasan tempat tinggal Responden bersama dengan anak tersebut. Ia dapat dilihat di dalam Afidavit Jawapan Responden dan surat*

pengesahan dari “Stay N Play” yang ditandakan sebagai ekshibit MA-2.

Berdasarkan kepada empat (4) perkara di atas, Mahkamah berpendapat bahawa Responden telah melanggar terma lawatan di Perenggan 6 Perintah bertarikh 17 April 2017 berdasarkan kejadian yang berlaku pada hari Khamis minggu kedua pada bulan Ogos 2017 bertarikh 10 haribulan.

11) Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana terus memutuskan kes Notis Tunjuk Sebab tersebut tanpa menjalankan siasatan lanjut sebab-sebab atau punca kepada pelanggaran perintah Mahkamah khususnya berkaitan fakta bahawa Perayu ada membalas mesej Responden menyatakan bahawa *“Mohsin has class and am conscious that it is raining traffic is bad. Please be informed”*. Dalam rayuan ini kami dapati YA Hakim Bicara terus membuat kesimpulan bahawa alasan hujan dan keadaan trafik tidak boleh diterima kerana aktiviti anak tersebut di *“Stay N Play”* terletak di Level 1, di bangunan yang sama dengan tempat tinggal Responden. Selain daripada itu kami juga tidak menemui adanya ulasan lain yang dibuat oleh YA Hakim Bicara berkaitan alasan hujan dan trafik sesak tersebut untuk menunjukkan ianya telah dipertimbangkan oleh YA Hakim Bicara.

12) Kami dapati masej tersebut yang dihantar oleh Perayu kepada Responden jam 5.18 petang adalah untuk memaklumkan berkenaan kelewatan Perayu dari tempat kerjanya untuk menyerahkan anak tersebut kepada Responden. Ini menunjukkan kepada kami bahawa kegagalan Perayu melaksanakan Perintah Mahkamah pada waktu tersebut bukanlah suatu yang terang-terang disengajakan tetapi terlewat disebabkan kekangan keadaan hujan dan trafik yang sesak dari tempat kerja Perayu ke rumahnya. Apa yang kami boleh simpulkan di sini ialah YA Hakim Bicara telah mengendalikan perosiding bagi Notis Tunjuk Sebab ini dengan tidak berhati-hati.

12) Seharusnya dalam kes yang melibatkan tindakan pengkomitan YA Hakim Bicara perlu mempertimbangkan dengan lebih berhati-hati sepertimana penekanan yang telah dibuat oleh Mahkamah dalam kes **Helen Yeap Poh Sin lwn. Universal Trustee (Malaysia) Sdn. Bhd (2001)** dan kes **Haji Azman bin Abdul Talib lwn. Suhaila Binti Ibrahim 92004) CLJ (Sya) 392** yang menyatakan;

“Kuasa Mahkamah untuk mengkomitkan seseorang ke penjara kerana kegagalan mematuhi perintah Mahkamah perlu dijalankan dengan berhati-hati”.

13) Dalam mengendalikan perbicaraan yang melibatkan tindakan pengkomitan khususnya yang berkait dengan kebajikan anak yang masih

kecil, YA Hakim Bicara boleh menggunakan kaedah inquisitorial dalam mempertimbangkan punca atau sebab-sebab berlaku pelanggaran terhadap perintah Mahkamah untuk mengelak daripada menjalankan prosiding yang hanya untuk menentukan sama ada berlaku pelanggaran atau keengkaran mematuhi perintah Mahkamah sahaja. Panduan dalam mempertimbangkan tunjuk sebab bagi tindakan pengkomitan ini telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dan dengan hormatnya kami merujuk kes **Zetty Binti Zabir lwn. Mohammed Rafi Bin Mohamed Yaacob, JH 36 BHG. I, 1434H, halaman 161-179.**

“ Berdasarkan Alasan Penghakiman tersebut, jelas bahawa YA Hakim Bicara menolak sepenuhnya tunjuk sebab tersebut tanpa menilai sama ada tunjuk sebab tersebut wajar dan munasabah. Ini menjadikan prosiding pengkomitan itu sebagai suatu prosiding hanya untuk menentukan sama ada berlaku pelanggaran/keengkaran mematuhi perintah Mahkamah.

Kami ingin memberikan panduan di sini bahawa di dalam prosiding pengkomitan, Mahkamah bukan sahaja perlu memutuskan sama ada berlaku keengkaran, tetapi juga perlu memutuskan sama ada patut Penghutang Penghakiman dikomitkan setelah mempertimbangkan sebab-sebab yang membawa keengkaran mematuhi perintah.”.

14) Kami juga mendapati keputusan kes ini telah dibacakan oleh Pendaftar pada 5 Disember 2018 iaitu setelah sebutan di hadapan Pendaftar pada 1 Oktober 2018 yang mengarahkan Responden memfailkan Afidavit Balasan pada 15 Oktober 2018 dan hujah pihak-pihak pada 15 November 2018. Selepas pihak-pihak melengkapkan pliding dan tanpa pemfailan hujah, kes ini tidak pernah ditetapkan pendengaran di hadapan YA Hakim Bicara. YA Hakim Bicara terus membuat keputusan berdasarkan pliding pihak-pihak dan mengarahkan keputusan tersebut dibacakan oleh Pendaftar. Keadaan ini juga menunjukkan kepada kami bahawa YA Hakim Bicara telah tidak berhati-hati dalam mengendalikan prosiding bagi kes ini sehingga terkhilaf dengan tidak menimbangkan apakah sebab-sebab atau punca-punca yang membawa kepada ketidak patuhan Responden terhadap Perintah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah.

16) Kami ingin menarik perhatian YA Hakim Bicara bahawa dalam kes ini tindakan pengkomitan adalah terhadap Responden sebagai hadhinah kepada anak yang berumur 7 tahun. Apa-apa keputusan Mahkamah berkaitan pengkomitan akan memberi kesan kepada anak tersebut. Mizan atau pertimbangan Mahkamah dalam kes seumpama ini seharusnya lebih berhati-hati agar isu kebajikan dan masalah anak

"المحضون" hendaklah diutamakan berbanding kehendak ibu dan bapa kanak-kanak tersebut sepertimana yang dinyatakan dalam kitab *Fiqh As-Sunnah*, Juzuk 2 1415/1995 halaman 234;

إن لكل من الحضانة والمحضون حقا في الحضانة, إلا أن حق المحضون أقوى من
الحضانة

Maksudnya:-

"Sesungguhnya setiap penjaga dan anak jagaan masing-masing mempunyai hak. Akan tetapi hak anak atau kemaslahatan anak lebih penting dari hak penjaganya"

17) Dengan hormatnya kami juga ingin kemukakan pandangan Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan di dalam kes Mohd Radhi bin Haji Che Daud lwn Khadijah binti Yaacob [2004] JH 17(1) iaitu -

"Tujuan hadhanah atau penjagaan kanak-kanak ialah untuk masalah dan kebaikan kanak-kanak yang dipelihara sebagai hak asasi bagi kanak-kanak itu dan hak itu mesti diutamakan lebih dari hak pihak yang ingin memelihara mereka."

Oleh yang demikian sangat penting untuk Mahkamah lebih berhati-hati dalam mengendalikan perbicaraan yang melibatkan tindakan pengkomitan agar tindakan tersebut tidak sampai ke tahap yang boleh menjejaskan kebajikan kanak-kanak.

18) Berdasarkan ulasan yang telah dikemukakan, kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf mensabitkan Perayu telah melanggar Perenggan 6 Perintah bertarikh 17 April 2017. Keadaan ini menyebabkan kami perlu campurtangan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah kedua-dua pihak, kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu adalah **DITERIMA**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam Kes Permohonan No. ^{0734-397 X} 10400-075-0150-2018 bertarikh 5 Disember 2018 adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh;

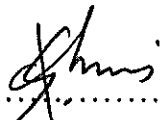


-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



-
2. **YA DATO'HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

10